

学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑤までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、乙が甲に向けて拳銃を発射してきたので、防衛のため、殺意をもって、携帯していた拳銃を乙に向けて発射した。その弾丸は、乙に当たり乙を死亡させるとともに、乙を貫通して、たまたま乙のそばを通り掛かった丙にも当たって丙を死亡させた。

【会話】

学生A. 私は、甲の行為は、乙に対する殺人既遂罪と丙に対する殺人既遂罪の構成要件に該当すると考えます。そして、乙に対する行為については、正当防衛が成立すると考えます。これを前提として丙に対する行為について検討しましょう。私は、①(a. 正当防衛・b. 緊急避難)が成立すると考えます。

学生B. 私は、Aさんの見解に反対です。この事例のように、防衛行為によって攻撃者以外の第三者の法益を侵害した場合、第三者との関係は、「正対不正」の関係とはいえないと考えるからです。私は、丙に対する行為については、②(c. 正当防衛・d. 緊急避難)が成立すると考えます。

学生A. 私は、②(c. 正当防衛・d. 緊急避難)が成立するためには、当該第三者の法益を侵害したことによって初めて現在の危難を避けることができたという関係が必要だと考えるので、Bさんの見解には反対です。Cさんは、どう考えますか。

学生C. 甲は、主観的には③(e. 正当防衛・f. 緊急避難)と認識して拳銃を発射し、丙に死亡の結果が発生しているので、丙に対する行為については、④(g. 誤想防衛・h. 誤想避難)であると考えます。そして、④(g. 誤想防衛・h. 誤想避難)についての判例の立場によれば、⑤(i. 違法性・j. 故意)が阻却されると考えます。

1. ①a ②d ③e ④g ⑤j
2. ①b ②c ③f ④h ⑤i
3. ①a ②d ③f ④h ⑤j
4. ①b ②c ③e ④h ⑤j
5. ①a ②d ③e ④g ⑤i

No104

予備H28-5

第三者に対する防衛行為

正 解

1

正答率

87%

() には順に、「① a ② d ③ e ④ g ⑤ j」と入り、したがって、正解は肢1となる。

①について

学生Aの見解に対して、学生Bは、防衛行為によって攻撃者以外の第三者の法益を侵害した場合、第三者との関係は、「正対不正」の関係とはいえないと批判する。学生Bの発言からすると、学生Aは防衛行為者と第三者の関係を「正対不正」と捉える立場に立つ。正当防衛は、「不正」な「侵害」者に対する反撃行為であり(36条1項)、「正対不正」の場面を前提とする。他方、緊急避難は、正当な利益を有する第三者を犠牲にして自己等の利益を守る行為であり(37条1項本文)、「正対正」の場面を前提とする。よって、防衛行為者と第三者の関係を「正対不正」と捉えるAの立場に立つと、丙の行為については正当防衛が成立する。したがって、①には、「a. 正当防衛」が入る。

②について

学生Bは、学生Aの立場に反対する立場、すなわち、防衛行為者と第三者との関係を「正対正」と捉える立場に立つ。そして、正当防衛は、「不正」な「侵害」者に対する反撃行為であり(36条1項)、「正対不正」の場面を前提とする。他方、緊急避難は、正当な利益を有する第三者を犠牲にして自己等の利益を守る行為であり(37条1項本文)、「正対正」の場面を前提とする。よって、防衛行為者と第三者の関係を「正対正」と捉えるBの立場に立つと、丙の行為については緊急避難が成立する。したがって、②には、「d. 緊急避難」が入る。

③について

【事例】では、甲は、「防衛のため」、拳銃を乙に向けて発射し、丙を死亡させている。すなわち、甲は主観的には自己の行為が正当防衛に当たるとの認識で当該行為を実行している。したがって、③には、「e. 正当防衛」が入る。

④について

【事例】では、甲は、主観的には正当防衛と認識して拳銃を発射しており、甲には故意非難を向け得る主観的事情は存在しない。当該状況は、急迫不正の侵害が存在しないのにそれが存在すると誤信して、それに対して反撃行為を行うという誤想防衛のケースと類似していると評価できる。したがって、④には、「g. 誤想防衛」が入る。

⑤について

大判昭8.6.29は、誤想防衛につき、「其の行為が或は法令に因り或は其の他法律上犯罪の成立を阻却すべき客観的原因に基く場合なりとせば違法ならざるが故に罪とならざるは勿論にして、又斯かる客観的事実の現在すること無しとするも行為者が其の存在することを誤信したる場合に於ては犯意あると為すを得ず」として故意阻却の立場を採る。よって、⑤には、「j. 故意」が入る。